

1500083-64.2020.8.26.0058

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: ORLANDO GONÇALVES DE CASTRO NETO

Comarca: Agudos

Foro: Foro de Agudos

Vara: 1ª Vara Judicial

Data de Disponibilização: 10/02/2022

... estava em patrulhamento por local de tráfico e tinham informações de que o réu estaria praticando tráfico de drogas em ginásio em construção abandonado. Ao ver as viaturas, o réu saiu correndo. Pediram apoio, foram atrás dele em acompanhamento visual. Abordaram-no próximo de sua residência. Em busca pessoal, nada de ilícito foi encontrado. Sua mãe saiu de casa. O réu negou ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Agudos

Foro de Agudos

1ª Vara Judicial

Rua Paulo Nelli, 276, Agudos-SP - cep 17120-370

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

1500083-64.2020.8.26.0058 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500083-64.2020.8.26.0058

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência, Portaria, Boletim de Ocorrência, Portaria, Boletim de Ocorrência - 2075406/2020 - DEL.POL.AGUDOS, 6763962 - DEL.POL.AGUDOS, 348/20/101 - DEL.POL.AGUDOS, 2075406 - DEL.POL.AGUDOS, 348/20/101 - DEL.POL.AGUDOS, 2075406 - DEL.POL.AGUDOS, 348/20/101 - DEL.POL.AGUDOS

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ABRAAO TEODORO MARCOS

Juiz(a) de Direito: Dr(a). ORLANDO GONÇALVES DE CASTRO NETO

Vistos.

I - RELATÓRIO.

ABRAAO TEODORO MARCOS, qualificado nos autos, foi denunciado pelo Ministério Público de São Paulo como incurso no Art. 33, caput, e §1º, inciso II, ambos da Lei n. 11.343/06, pois, segundo a denúncia, no dia 20 de fevereiro de 2020, por volta das 21 horas e 30 minutos, na Rua Tenente Armando Gonzaga, n. 100, Centro, nesta cidade e comarca de Agudos, o denunciado tinha em depósito, para entrega ao consumo de terceiros, 07 porções de crack, com massa líquida de total de 0,68g (sessenta e oito centigramas), 16 porções de cocaína, com massa líquida total de 3,55g (três gramas e cinquenta e cinco centigramas) e 03 porções de fragmentos vegetais de "maconha", com massa líquida total de 5,87g (cinco gramas e oitenta e sete

centigramas), conforme laudo de constatação provisória, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar (fls. 103/106). Consta ainda que, nas mesmas circunstâncias temporais, na Rua Tenente Armando Gonzaga, n. 100, Centro, nesta cidade e comarca de Agudos, o réu semeava e cultivava 01 porção de planta arbustiva de "maconha", com massa líquida total de 4,11 (quatro gramas e onze centigramas), matéria-prima para a preparação de drogas, em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme auto de apreensão de fls. 06/07 e laudo químico toxicológico definitivo de fls. 10/15.

Boletim de ocorrência às fls. 04/05.

Auto de exibição e apreensão às fls. 06/07.

Laudo pericial às fls. 10/15.

Houve recebimento da denúncia em 19/10/2021 (fls. 74/75).

Notificado às fls. 116, o réu apresentou defesa prévia às fls. 120.

Em 10 de fevereiro de 2022, foi realizada audiência virtual de instrução e debates orais gravados em sistema audiovisual, realizada pelo aplicativo Microsoft Teams, atendendo ao disposto nos comunicados CGJ nº. 284/2020 e 317/2020, quando foram ouvidas duas testemunhas de acusação e o réu, ao final, foi interrogado.

As alegações finais foram ofertadas oralmente pelas partes e gravadas em sistema audiovisual através do aplicativo Microsoft Teams, atendendo ao disposto nos comunicados CGJ nº. 284/2020 e 317/2020.

É o relatório.

Fundamento e decido.

II - FUNDAMENTAÇÃO.

O feito encontra-se em ordem. Presentes os pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, bem como as condições da ação e os pressupostos processuais, pertinente a análise do mérito da causa.

A materialidade delitiva restou comprovada nos autos pelo boletim de ocorrência policial (fls. 04/05), auto de exibição e apreensão (fls. 06/07), laudos de exame químico toxicológico (fls. 10/15), bem como pela prova oral produzida em audiência.

Quanto à autoria, necessária detida análise da prova oral produzida.

Em Delegacia, o policial militar Fabio Ronaldo Tavera contou que "no dia 20/02/20, por volta de 21h30, estava de serviço juntamente com seu colega de farda, Cb Richard, em patrulhamento pela Rua Tenente Armando de Oliveira Gonzaga, Profº. Simões, Agudos, local conhecido como ponto de venda de entorpecentes, quando avistaram um sujeito, o qual se evadiu correndo ao avistar a viatura, sendo acompanhado e abordado defronte à casa dele, localizada na Rua José Silveira Rodrigues Junior, 138, Profº Simões, Agudos. Na posse desse sujeito, identificado como sendo ABRAÃO TEODORO MARCOS, nada de ilícito foi localizado, porém, ao realizarem buscas no interior da residência de Abraão, localizaram dentro da churrasqueira 16 eppendorf's, contendo substância semelhante à cocaína, 03 invólucros plásticos contendo substância esverdeada semelhante à maconha, além de um pé de planta semelhante à maconha, que estava ao lado da churrasqueira. Afirma que retornaram ao local onde Abraão estava antes de fugir para a residência dele e lá localizaram no chão 07 pedras de uma substância semelhantes a crack. Questionado

sobre os entorpecentes localizados, Abraão afirmou que as drogas encontradas em sua casa lhe pertenciam, já a droga localizada no local de onde ele havia fugido alegou não ser de sua propriedade (...)" (fls. 35). [grifamos].

Em Delegacia, o policial militar Richard Garcia disse que "no dia 20/02/20, por volta de 21h30, estava de serviço juntamente com o seu colega de farda, Sgto Tavera, em patrulhamento pela Rua Tenente Armando de Oliveira Gonzaga, Profº Simões, Agudos/SP, local conhecido como ponto de venda de entorpecentes, quando avistaram um sujeito, o qual se evadiu correndo ao avistar a viatura, sendo acompanhado e abordado defronte à casa dele, localizado na Rua José Silveira Rodrigues Junior, 138, Profº Simões, Agudos. Na posse desse sujeito, identificado como sendo ABRAÃO TEODORO MARCOS, nada de ilícito foi localizado, porém, ao realizarem buscas no interior da residência de Abrrão, localizaram dentro da churrasqueira 16 eppendof's, contendo substância semelhante à cocaína, 03 invólucros plásticos, contendo substância esverdeada semelhante à maconha, além de um pé de planta semelhante à maconha, que estava do lado da churrasqueira. Afirma que retornaram ao local onde Abraão estava antes de fugir para a residência dele e lá localizaram no chão 07 pedras de uma substância semelhante à crack. Questionado sobre os entorpecentes localizados, Abraão afirmou que as drogas encontradas em sua casa lhe pertenciam, já a droga localizada no local de onde ele havia fugido alegou não ser de sua propriedade (...)." (fls. 36). [grifamos]

Em juízo, a testemunha e policial Fabio Ronaldo Tavera, devidamente compromissado, disse que, em patrulhamento com sua equipe em local conhecido pelo tráfico, viu um indivíduo saindo correndo, o qual foi acompanhado e abordado em sua residência, na qual fizeram busca e encontradas as drogas indicadas na denúncia. Ao retornarem ao local que deu origem à abordagem, encontraram mais 7 pedras de crack. Disse que o acusado negou a propriedade dessas drogas e assumiu as de sua casa. Disse que o réu chegou a entrar em sua casa. Chamaram-no. Sua mãe tumultuou um pouco. A entrada na casa foi autorizada pela mãe e pelo acusado. A mãe ficou bastante nervosa, mas concordou. No local de início, não tem certeza, mas acha que o réu estava sozinho. O réu chegou correndo um pouco antes da viatura, entrou na casa dele, foi indagado, então saiu até a calçada, disse que estava com medo da abordagem etc.

Em juízo, a testemunha e policial militar Richard Garcia, devidamente compromissado, disse que estava em patrulhamento por local de tráfico e tinham informações de que o réu estaria praticando tráfico de drogas em ginásio em construção abandonado. Ao ver as viaturas, o réu saiu correndo. Pediram apoio, foram atrás dele em acompanhamento visual. Abordaram-no próximo de sua residência. Em busca pessoal, nada de ilícito foi encontrado. Sua mãe saiu de casa. O réu negou que tivesse drogas e autorizou a entrada das equipes em sua residência. Lá, encontraram as drogas descritas na denúncia. Foi levado à Delegacia, mas o flagrante não foi ratificado. Próximo do local de início, retornaram e encontraram 7 pedras de crack. Foi abordado em frente sua residência. Não deu tempo de que ele entrasse na casa. Houve autorização dele e da mãe para a entrada na casa. Não soube dizer por que o flagrante não foi ratificado.

Ressalte-se, por oportuno, que os policiais não estão impedidos de depor pela legislação processual pátria. O fato de serem servidores comprometidos com a aplicação da lei, repressão e combate ao crime não retira a força de suas palavras. Pelo contrário, suas palavras têm pleno crédito até que prova manifesta em contrário exclua a presunção. Ademais, não há motivos para distinguir a validade do depoimento de policiais das demais provas orais produzidas em juízo, uma vez que eles, como quaisquer testemunhas, depõem sob compromisso, devendo ser presumida, por isso, a veracidade de suas informações, até que se demonstre cabalmente o contrário.

Da jurisprudência, trago à colação: não há óbice a que os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante do réu sejam considerados na sentença como

elemento de prova amparador da condenação, desde que colhidos sob o crivo do contraditório e em harmonia com os demais elementos de cognição, tal como na hipótese" (STJ, HC nº 162.131/ES, relator Min. Og Fernandes, 6ª Turma, j. 25/05/2010).

Na Delegacia, o acusado Abraão alegou que as drogas e o pé de maconha localizados em sua residência eram para seu consumo próprio, bem como que consumiu toda a droga que estava com ele no ginásio, local da abordagem policial, não sendo de sua propriedade as 07 pedras de crack localizadas posteriormente. Por fim, declarou que não comercializava as drogas, apenas as utilizada para consumo pessoal (fls. 16).

Interrogado em juízo, o acusado Abraão disse que as drogas encontradas em sua casa eram suas para consumo próprio. Quando sai, já sai com um tanto para seu consumo. O pé de maconha é seu também. Nega a propriedade das pedras de crack. Havia diversas pessoas usando droga no local em que ele também estava e onde foram encontradas as pedras de crack. Disse que todos correram. Não tinha dinheiro com ele. Chegou a entrar em sua casa, mas saiu para ir a um bar próximo. Então, os policiais apareceram e o prenderam, entrando em sua casa em seguida após a chegada de outro policial. Não autorizou a entrada deles em sua casa. Os policiais não lhe perguntaram nada. Não sabe dizer se sua mãe autorizou. Não sabe que conversa tiveram com ela. Sua mãe estava bastante nervosa, chorando. Depois, foi levado para a viatura. Na Delegacia de Lençóis, foi ouvido no próprio dia dos fatos e depois na Delegacia de Agudos. Contou que estava consumindo cocaína e maconha no dia dos fatos quando viu as viaturas. Consome apenas maconha atualmente, mas na época também cocaína.

Pois bem.

II.A - DA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO.

No caso em tela, no que tange às drogas encontradas em sua residência, a despeito da materialidade do delito, o réu deve ser absolvido em razão da ilicitude da prova, que por sua vez decorreu da ilegalidade na violação do domicílio de Abraão.

Explico.

A violação do domicílio do réu seria admitida em três situações: (i) Primeira, se houvesse autorização judicial para tanto. (ii) Segunda, se houvesse consentimento válido e inequívoco do morador. (iii) Terceira, se houvesse fundadas razões concretas da ocorrência de flagrante delito no local.

Com a devida vênia aos respeitáveis entendimentos judiciais em contrário, entendo que nenhuma delas estava presente no caso em tela.

A ausência de autorização judicial para tanto é incontroversa.

Sobre o consentimento do morador, assim discorre o Professor Pierpaolo Cruz Bottini em artigo publicado no site Conjur<https://www.conjur.com.br/2014-nov-11/direito-defesa-buscas-policiais-mandado-parecem-normatizado>:

"Como pontua a doutrina processual penal, durante o dia ou à noite, o morador pode permitir a entrada em sua casa e, nessa situação, dispensa-se mandado judicial para realização de busca domiciliar. O consentimento, porém, deve ser real e livre, desprovido de vícios como o erro, violência ou intimidação. ([3]) Evidentemente que, em cada caso concreto, o consentimento do morador deve ser analisado com cautela e nunca presumido, especialmente para que se evitem abusos da autoridade policial. Sobre o cenário de muitos casos brasileiros, Cleunice Pitombo destaca: Infelizmente, no Brasil e em outros lugares, em que o miúdo desconhece os próprios direitos, o abuso policial surge manifesto. A polícia invade casas e o morador,

temeroso, tímido, não lhe coarctar o passo. ([4]) O TJ-RS recentemente destacou a invalidade do consentimento de pessoa investigada por tráfico de drogas. Na ocasião, o desembargador relator pontuou: "Não existe previsão legal para a busca domiciliar a partir da permissão informal do proprietário. Do consentimento a que se refere o artigo 5º, XI, da Constituição Federal não se infere que poderão ser realizadas buscas sem determinação judicial, apenas sob a anuência do morador. Se assim fosse, veríamos-nos diante de um quadro temerário, no qual os mandados de busca e apreensão seriam dispensáveis, já que polícia sempre poderia conseguir, extrajudicialmente, o 'consentimento' do proprietário. Afinal, é de se ter em conta que, nas circunstâncias descritas nos autos esse aval foi dado sob constrangimento" (Ap 70058172628, relator desembargador Diógenes V. Hassan Ribeiro, 3ª Câmara Criminal, DJ 24.06.2014). Destarte, se há o consentimento do morador para buscas domiciliares, algumas questões devem ser bem refletidas: (i) forma do consentimento; (ii) pessoa que consente e seu grau de esclarecimento sobre as implicações da medida. Sobre a forma do consentimento, deve ser expresso e jamais presumido, sendo que não há previsão legal de forma especial. Relevante destacar doutrina portuguesa que pontua a necessidade de documentação do consentimento, por qualquer forma, mesmo gravada: "Relativamente à forma do consentimento, parece-nos resultar da lei que o mesmo não pode ser dado de forma tácita, nem por via de presunção. A exigência de consentimento expresso pode retirar-se da circunstância de a lei impor obrigatoriamente a documentação do mesmo. (...). Já no que respeita à forma de documentação do consentimento, o Acórdão da Relação de Lisboa de 13 de Janeiro de 2000 veio pronunciar-se no sentido de que a lei processual penal não exige forma especial (pode ser verbal), bastando que o mesmo seja prestado anteriormente à busca e fique, de qualquer forma, documentado. A documentação do consentimento verbal pode ser efetuada, por exemplo, através de gravação sonora". ([5]) No tocante à pessoa que consente, deve ser aquele titular do direito à inviolabilidade do domicílio. A doutrina destaca que a permissão deve ser do próprio sujeito da medida de busca e apreensão ou de outra pessoa que possa, legitimamente, representá-lo. Ressalvas são feitas, ainda, às habitações coletivas, em que o consentimento por um dos moradores não autoriza a busca na casa ou aposento de terceiros. ([6]) No entanto, maior relevo tem a questão do grau de esclarecimento do morador que consentiu na realização da busca e apreensão. Para que se solucione o conflito de interesses – busca da verdade para realização da justiça e inviolabilidade do domicílio – por via consensual, é necessário que aquele que consente tenha pleno conhecimento das circunstâncias e consequências da realização da busca domiciliar, bem como que isso seja documentado. No ponto, não há previsão legal. Contudo, tratando-se de medida que pode implicar a produção de prova contra o próprio morador que consente com a busca, para que ele decida de forma justa e válida se franqueará a entrada em sua residência, necessário que no mínimo lhe sejam esclarecidos seus direitos e o alcance da inviolabilidade do domicílio, bem como as consequências da realização da busca domiciliar. A mesma lógica e o mesmo cuidado são observados nos procedimentos de interrogatórios, tanto judicial quanto policial, a fim de garantir o direito da pessoa de não produzir prova contra si (deriva das previsões constitucionais – artigo 5º, LVII e LXII – e consagrado do Pacto de São José da Costa Rica, artigo 8º). Nesse aspecto, surpreendem a doutrina e a jurisprudência espanhola, já sensibilizadas com a questão, ao sustentarem que o consentimento deve ser prestado em circunstâncias que garantam uma decisão consciente e ponderada pelo morador. Defendem, em resumo: "a) que o consentimento deve produzir-se em condições de serenidade e liberdade ambiental necessárias para autorizar a invasão de um direito fundamental como a inviolabilidade de domicílio; b) que, atendendo ao caráter fundamental do direito tutelado, a diligência se inicie com a informação do visado sobre o alcance do direito à inviolabilidade do domicílio e de seus limites, e com uma pergunta clara e concisa sobre se o visado tolera ou não a intromissão; c) a presença de um 'letrado', para garantir a autenticidade da manifestação de vontade, evitando perguntas capciosas ou sugestivas, bem como qualquer forma de coação ou ameaça; d) que entre a solicitação do consentimento e a resposta, por parte do visado, medeie um pedido de tempo suficiente para este meditar com calma sobre o assunto e

compreenda o significado e alcance da sua resposta". ([7]) (...) Conclui-se que a autorização para a violação do domicílio, nos casos de flagrante delito, depende de um estado de flagrância claro, constatado antes da invasão do domicílio e passível de demonstração posterior. As suspeitas, fundadas em relatos declarados ou ocultos, devem ser submetidas a prévia autorização judicial, mediante representação. Além disso, no ponto do consentimento, necessária observância de cuidados, a fim de assegurar que este seja consciente e válido. Frise-se que o consentimento não se presume e requer prova, cujo ônus é do Estado (TRF-2 Região, RSE 200551015058355, DJ 22.10.2008). Mais do que isso, parece-nos essencial que sejam esclarecidos, ao sujeito da medida e de forma documentada, os seus direitos, o alcance da inviolabilidade do domicílio e as consequências de sua decisão por franquear a entrada de policiais para a busca domiciliar. Trata-se de medidas mínimas para coibir abusos da autoridade policial e fazer valer um Estado Democrático de Direito." [negrito nosso; itálico no original].

No caso em tela, não há qualquer prova nos autos de que tenha havido consentimento voluntário e válido do acusado Abraão, que já havia entrado em casa e foi chamado para fora pelos policiais militares, momento após o qual, sem autorização judicial, ingressaram na residência, tendo permanecido na viatura.

Mais que isso, a suposta autorização de entrada teria sido dada por terceiro (mãe do réu), pessoa não investigada, ou seja, que jamais poderia consentir em nome de seu filho, que, salvo melhor juízo, é plenamente capaz.

Além disso, não há nos autos notícia de que a mãe do acusado foi devidamente informada que poderia negar a entrada dos agentes policiais, bem como não houve sua oitiva em sede policial ou em juízo. Tampouco há notícia de que o acusado foi informado de seus direitos e de que poderia negar a entrada policial.

Salta aos olhos ainda o fato de que os depoimentos policiais se contradizem, pois o policial Tavera diz que o réu foi abordado após sair de sua casa, onde já estava quando chegaram as viaturas, enquanto o policial Richard disse que o abordaram antes que ele entrasse em sua residência, fazendo com que os depoimentos percam sua presunção de veracidade e façam surgir dúvida razoável da dinâmica dos fatos.

E, ainda que tivesse havido consentimento válido, não foi demonstrado que o réu ou sua mãe foram previamente informados de seus direitos e das consequências da realização da busca e apreensão, sendo manifesta a coação – ao menos indireta – que a abordagem realizada por policiais militares ou civis fortemente armados causa nos indivíduos, mormente naqueles desconhecedores de seus direitos mínimos.

O homem médio brasileiro, profundo desconhecedor de suas garantias mínimas, sente-se coagido diante de tal interpelação policial, sendo que, às vezes, dá permissão para a prática de atos pelos agentes do Estado, aos quais não está obrigado a se submeter, mas o faz por receio do que pode advir de sua negativa.

Não se cuida aqui de desmerecer a valorosa atividade policial ou de presumir a prática de coações por parte dos policiais. Ao contrário, o que se pondera é justamente o medo que os cidadãos em geral possuem de contrariar as autoridades estatais por conta do desconhecimento do que é ou não lícito e ao que estão ou não obrigados.

Nesse mesmo sentido, destaco trecho do voto proferido pelo Ministro Rogério Schietti no julgamento do RESP nº 1.690.854 - RJ (2017/0208328-0):

"Por fim, merece destaque a afirmação constante dos autos de que, ao se dirigirem para a residência, os policiais tiveram a entrada franqueada pela proprietária do imóvel (fls. 3 e 256). Tal realidade, a meu ver, demonstra muito mais uma situação aguda, uma vontade externada sob domínio de intensa pressão, do que uma pouco

crível colaboração para que, voluntariamente, fosse autorizado o ingresso de agentes policiais em sua residência para a busca domiciliar. Em relação ao cenário brasileiro, Cleunice Pitombo, na mesma linha, destaca: "Infelizmente, no Brasil e em outros lugares, em que o miúdo desconhece os próprios direitos, o abuso policial surge manifesto. A polícia invade casas e o morador, temeroso, tímido, não lhe coarcta o passo" (Da busca e apreensão no processo penal. 2. ed. São Paulo: RT, 2005, p. 133-134)."

E nem se diga que, por se tratar o tráfico e a posse de drogas de crimes permanentes, havia situação de flagrante delito que justificasse o ingresso, pois, naquele caso, não havia nenhum elemento concreto que indicasse a prática de tráfico.

O depoimento dos dois policiais militares e do acusado são uníssomos ao afirmarem que nada de ilícito foi localizado com o Abraão no momento de sua abordagem e revista pessoal. Logo, não havia nenhum elemento concreto que indicasse a prática de tráfico de drogas e justificasse, portanto, sem autorização judicial, o ingresso na sua casa.

Os policiais sequer mencionam atos de traficância concreta do réu na ocasião, limitando-se a dizer que a conduta de "fuga" era suspeita e havia informações anônimas de que ele estaria praticando o tráfico de drogas. Apesar de não localizarem nada de ilícito em posse do réu, resolveram ingressar em sua residência.

Ora, deve-se lembrar que o ingresso em domicílio sem autorização judicial é medida bastante excepcional, justificável apenas quando houver elementos sólidos e concretos da existência de flagrante delito no local naquele momento e, sobretudo, quando for inviável a solicitação de mandado de busca e apreensão em razão da urgência.

Trago à baila, nesse sentido, recentes acórdãos do Superior Tribunal de Justiça (STJ), cujo entendimento atual das duas turmas responsáveis pelo julgamento dos casos penais é uniforme (em 02.03.2020, a Quinta Turma, por determinação do Supremo Tribunal Federal, proferiu juízo de retratação no RHC 89.853/SP, adequando o seu entendimento ao da Sexta Turma):

RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. FLAGRANTE. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. TEMA 280/STF. FUGA ISOLADA DO SUSPEITO. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. NULIDADE DE PROVAS CONFIGURADA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. 1. No RE n.º 603.616/Tema 280/STF, a Suprema Corte asseverou que a flagrância posterior, sem demonstração de justa causa, não legitima o ingresso dos agentes do Estado em domicílio sem autorização judicial e fora das hipóteses constitucionalmente previstas (art. 5º, XI, da CF). 2. Apesar de se verificar precedentes desta Quinta Turma em sentido contrário, entende-se mais adequado com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal o entendimento que exige a prévia realização de diligências policiais para verificar a veracidade das informações recebidas (ex: "campana que ateste movimentação atípica na residência"). 4. Recurso em habeas corpus provido para que sejam declaradas ilícitas as provas derivadas do flagrante na ação penal n.º 0006327-46.2015.8.26.0224, em trâmite no Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Guarulhos/SP. (STJ, RECURSO EM HABEAS CORPUS Nº 89.853 - SP (2017/0247930-4, juízo de retratação realizado por determinação do Supremo Tribunal Federal em 02.03.2020) [grifamos])

PROCESSUAL PENAL E PENAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTES. CORRUPÇÃO DE MENORES. ENTRADA EM DOMICÍLIO SEM ORDEM JUDICIAL E SEM ELEMENTOS MÍNIMOS DE TRAFICÂNCIA NO LOCAL. PRISÃO PREVENTIVA ILEGAL. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS PROVIDO. 1. Ainda que esta Sexta Turma tenha admitido como fundamento para a prisão

preventiva a relevante quantidade entorpecentes apreendidos em poder da paciente, tratando-se de 132 pedras de crack, 84 papelotes de cocaína e ainda 26 trouxinhas de maconha, não foi apontado nenhum elemento idôneo para justificar a entrada dos policiais na residência da paciente, citando-se apenas a verificação de denúncias de tráfico de drogas que receberam através do "Disque Denúncia", e a fuga do adolescente. 2. Verifica-se ofensa ao direito fundamental da inviolabilidade do domicílio, determinado no art. 5º, inc. XI, da Constituição da República, quando não há referência a prévia investigação policial para verificar a possível veracidade das informações recebidas, não se tratando de averiguação de informações concretas e robustas acerca da traficância no domicílio violado. 3. Recurso em habeas corpus provido, para a soltura da recorrente, TEREZA RODRIGUES, e de ofício determinar o trancamento da Ação Penal n. 0001783-23.2016.8.26.0695. (STJ, Sexta Turma, RHC 83.501/SP, Rel. Mini. Nefi Cordeiro, julgado em 06/03/2018) [grifamos]

RECURSO ESPECIAL. CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS E DE POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. FLAGRANTE. DOMICÍLIO COMO EXPRESSÃO DO DIREITO À INTIMIDADE. ASILO INVOLÁVEL. EXCEÇÕES CONSTITUCIONAIS. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA. INVASÃO DE DOMICÍLIO PELA POLÍCIA. NECESSIDADE DE JUSTA CAUSA. NULIDADE DAS PROVAS OBTIDAS. TEORIA DOS FRUTOS DA ÁRVORE ENVENENADA. ABSOLVIÇÃO QUE SE MOSTRA DEVIDA. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO. 1. O Supremo Tribunal Federal definiu, em repercussão geral, que o ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial apenas se revela legítimo - a qualquer hora do dia, inclusive durante o período noturno - quando amparado em fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, que indiquem estar ocorrendo, no interior da casa, situação de flagrante delito (RE n. 603.616/RO, Rel. Ministro Gilmar Mendes) DJe 8/10/2010). 2. Em nenhum momento, foi explicitado, com dados objetivos do caso, em que consistiria eventual atitude suspeita por parte do acusado, externalizada em atos concretos, tampouco foi feita menção a eventual movimentação de pessoas típica de comercialização de drogas. Não há referência a prévia investigação, monitoramento ou campanhas no local. Também não se tratava de averiguação de denúncia robusta e atual acerca da ocorrência de tráfico naquele local. Há apenas a descrição de que, quando o recorrido avistou os policiais militares, empreendeu fuga. 3. Uma vez que não há nem sequer como inferir, de fatores outros que não a mera fuga ante a iminente abordagem policial, que o recorrido estivesse praticando delitos de tráfico de drogas, de posse ilegal de arma de fogo de uso restrito, ou mesmo outro ato de caráter permanente, no interior da residência onde se homiziou, não há razão séria para a mitigação da inviolabilidade do domicílio, ainda que tenha havido posterior descoberta e apreensão, no domicílio do acusado, de drogas e de arma de fogo de uso restrito, sob pena de esvaziar-se essa franquia constitucional da mais alta importância. 4. No caso, houve mera intuição acerca de eventual traficância praticada pelo ora recorrido, o que não configurou, por si só, "fundadas razões" a autorizar o ingresso em seu domicílio, sem o seu consentimento e sem determinação judicial. 5. Recurso especial não provido. (STJ - REsp: 1690854 RJ 2017/0208328-0, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 27/02/2018, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/03/2018) [grifamos]

"Para obviar esse tipo de situação, que instabiliza e põe sob permanente risco referida franquia constitucional, não seria desarrazoado sustentar que a hipótese de flagrante delito a que alude o art. 5º, XI, da Constituição da República deveria ao menos em interpretação restritiva compatível para norma que, a rigor, excepciona importantíssima liberdade pública, denotar a situação em que um crime esteja ocorrendo no interior da residência e a urgência não permite aguardar a providência mais segura, cautelosa, a prévia autorização judicial." (Trecho do voto do Ministro Relator no acórdão supra mencionado). [grifamos]

Não se ignora aqui a tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal em repercussão geral no sentido de que "a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas "a posteriori", que indiquem que dentro da casa ocorre situação de

flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados." (STF. Plenário. RE 603616/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, julgado em 4 e 5/11/2015 (repercussão geral) (Info 806)).

Tal tese, todavia, deve ser adequadamente analisada e interpretada em cada caso concreto a fim de evitar se converter em salvo conduto para que a polícia ingresse em qualquer residência à procura de drogas em verdadeiras fishing expeditions. É preciso fazer, assim, a devida filtragem constitucional da expressão "fundadas razões", como vem fazendo o Superior Tribunal de Justiça nos julgados acima citados. O voto-vista do Ministro Rogério Schietti Cruz no RHC nº 83501/SP bem esclarece a situação:

"Não se desconhece que, consoante afirmou o Ministro Gilmar Mendes por ocasião do julgamento do referido RE n. 603.616/RO, "A busca e apreensão domiciliar é uma medida invasiva, mas de grande valia para a repressão à prática de crimes e para a investigação criminal" (p. 10 do acórdão). Também não perco de vista que, não raro, é tênue a distinção dos limites circunstanciais entre a legitimidade da ação de ingresso e a afetação do direito à inviolabilidade de domicílio. No entanto, é de particular importância (re)pensar em que medida o ingresso na esfera domiciliar para apreensão de drogas em determinadas circunstâncias representa uma intervenção restritiva legítima do ponto de vista constitucional, e não uma violação do direito fundamental à inviolabilidade de domicílio. Isso porque a ausência de justificativas e de elementos seguros a autorizar a ação dos agentes públicos, diante da discricionariedade policial na identificação de situações suspeitas relativamente à ocorrência de tráfico de drogas, pode acabar esvaziando o próprio direito à privacidade e à inviolabilidade de sua condição fundamental. Sobre esse cuidado de ocorrerem abusos na invasão de domicílio, Arion Escorsin de Godoy e Domingos Barroso da Costa advertem que: Sabe-se que o flagrante autoriza a violação de domicílio, mas essa relativização do direito fundamental previsto no inc. XI do art. 5º da Constituição não significa abertura a ações policiais que mais se assemelham a apostas lotéricas, em que o prêmio – dependente da sorte do jogador – é o encontro de indícios da prática de tráfico de drogas e a consequente prisão de quem possa ser seu autor. Desconstruindo a afirmativa que deve ser analisada frente às narrativas comuns aos autos de prisão em flagrante por tráfico de drogas, descobre-se que, em regra, não há uma situação de flagrância comprovadamente constatada antes da invasão de domicílio, o que a torna ilegal, violadora de direito fundamental. Porém, como em um passe de mágica juridicamente insustentável, por uma convalidação judicial, a apreensão de objetos ou substâncias que sejam proibidos ou indicativos da prática de crime e a prisão daquele(s) a quem pertença(m) travestem de legalidade uma ação essencialmente – e originariamente – violadora de direito fundamental. E a realidade pode ser ainda mais perversa, na medida em que se sabe que abusos policiais não são tão incomuns quanto se deseja, não sendo raros os casos de manipulação das circunstâncias, como se dá nos chamados flagrantes forjados. (O consentimento e a situação de flagrante delito nas buscas domiciliares). Não se há de admitir, portanto, que a mera constatação de situação de flagrância, posterior ao ingresso, justifique a medida. Ora, se o próprio juiz (um "terceiro neutro e desinteressado") só pode determinar a busca e apreensão durante o dia e, mesmo assim, mediante decisão devidamente fundamentada, após prévia análise dos requisitos autorizadores da medida, não seria razoável conferir a um servidor da segurança pública total discricionariedade para, a partir de mera capacidade intuitiva, entrar de maneira forçada na residência de alguém e, então, verificar se nela há ou não alguma substância entorpecente." [grifamos]

Veja-se que, nos acórdãos citados, além de denúncias anônimas, houve a fuga do acusado e até o "consentimento" do morador, mas, mesmo assim, entendeu-se ilícita a prova obtida em virtude da fragilidade dos elementos.

Aliás, o próprio Ministro relator Gilmar Mendes, no julgamento do RE n. 603.616/RO acima mencionado, fez importantes considerações e ressalvas sobre os requisitos do

ingresso no domicílio sem mandado judicial, na mesma linha do que vem fazendo o STJ (inclusive com expressa referência aos julgados de tal tribunal):

“O policial pode invocar o próprio testemunho para justificar a medida. Claro que o ingresso forçado baseado em fatos presenciados pelo próprio policial que realiza a busca coloca o agente público em uma posição de grande poder e, por isso mesmo, deve merecer especial escrutínio. No entanto, ao ouvir gritos de socorro e ruídos característicos de uma briga vindos de dentro de uma residência, o policial tem fundadas razões para crer que algum crime está em andamento no ambiente doméstico. Não se deve exigir que busque confirmação adicional para agir. Por outro lado, provas ilícitas, informações de inteligência policial – denúncias anônimas, afirmações de “informantes policiais” (pessoas ligadas ao crime que repassam informações aos policiais, mediante compromisso de não serem identificadas), por exemplo – e, em geral, elementos que não têm força probatória em juízo não servem para demonstrar a justa causa. A esse respeito, registro que a jurisprudência desta Corte não vê em elementos desprovidos de valor probatório força suficiente para adoção de medidas invasivas. Os precedentes vão no sentido de que nem mesmo investigações criminais podem ser instauradas sem um mínimo de indícios da ocorrência da infração. Nesse sentido, especificamente sobre a denúncia anônima, decidiu-se no Inq. 1957, Rel. Min. Carlos Velloso, Tribunal Pleno, DJ 11.11.2005. Bem pontuou o Ministro Celso de Mello: “(a) os escritos anônimos não podem justificar, só por si, desde que isoladamente considerados, a imediata instauração da persecutio criminis, eis que peças apócrifas não podem ser incorporadas, formalmente, ao processo, salvo quando tais documentos forem produzidos pelo acusado, ou, ainda, quando constituírem, eles próprios, o corpo de delito (como sucede com bilhetes de resgate no delito de extorsão mediante sequestro, ou como ocorre com cartas que evidenciem a prática de crimes contra a honra, ou que corporifiquem o delito de ameaça ou que materializem o crimen falsi, p. ex.); (b) nada impede, contudo, que o Poder Público provocado por delação anônima (disque-denúncia p. ex.), adote medidas informais destinadas a apurar, previamente, em averiguação sumária, com prudência e discricção, a possível ocorrência de eventual situação de ilicitude penal, desde que o faça com o objetivo de conferir a verossimilhança dos fatos nela denunciados, em ordem a promover, então, em caso positivo, a formal instauração da persecutio criminis, mantendo-se, assim, completa desvinculação desse procedimento em relação às peças apócrifas;” Na mesma linha é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça – AgRg no REsp 1521711/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 21.5.2015. Nada impede, contudo, que essas informações venham a dar base a pesquisas e, uma vez robustecidas por outros elementos, embasem a busca. Logo, a tese é coerente com a jurisprudência acerca do lastro mínimo para medidas invasivas. A solução preconizada não tem a pretensão de resolver todos os problemas. A locução fundadas razões demandará esforço de concretização e interpretação. Haverá casos em que o policial julgará que dispõe de indícios suficientes para a medida e o Juízo decidirá em contrário. O fundamental é que se passa a ter a possibilidade de contestação de uma medida de busca e apreensão que deu resultados. Assegura-se à defesa a oportunidade de impugnar, em um processo contraditório, a existência e suficiência das razões para a medida. Ou seja, a validade da busca é testada com base no que se sabia antes de sua realização, não depois. A mudança cria espaço para formação de jurisprudência acerca dos limites da atuação policial, possibilitando o desenvolvimento e a concretização da garantia, a partir da avaliação jurisprudencial dos casos concretos.” [grifamos]

Portanto, pelo contexto fático delineado nos autos em análise, em que pese eventual boa-fé da polícia, não havia elementos concretos que justificassem a invasão de domicílio sem a prévia autorização judicial.

Eis a razão pela qual, dado que a casa é asilo inviolável do indivíduo, desautorizado estava o ingresso na residência, de maneira que as provas obtidas por meio da medida invasiva são ilícitas, bem como todas as que delas decorreram (por

força da Teoria dos Frutos da Árvore Envenenada – art. 157, §1º, CPP), o que impõe a absolvição por ausência de provas acerca da materialidade do delito de tráfico de drogas.

Não desconheço que, aos olhos de um leigo, soe desarrazoado se permitir a absolvição de alguém que talvez fosse "materialmente culpado" pelo fato de a prova contra ele ter sido produzida por meios ilícitos, porque, para o senso comum, os fins justificam os meios. Ocorre que, no atual estado civilizatório do Estado Democrático de Direito, a atividade estatal encontra-se balizada por regras de atuação claras e previamente estabelecidas, as quais devem ser rigidamente obedecidas.

Se a Constituição exige requisitos para a violação do domicílio, é porque entende que a intimidade e a privacidade dos indivíduos são valores fundamentais a serem preservados, ainda que isso possa, em alguns casos, dificultar o combate à criminalidade. E não é preciso muita criatividade para imaginar quão grave seria permitir que, a pretexto de procurar objetos ilícitos, a polícia entrasse a qualquer momento na casa de qualquer pessoa – ou seja, qualquer um de nós – revirando tudo em busca de algo ilícito.

Direitos individuais fundamentais não surgiram por acaso. Decorreram de luta histórica contra abusos e excessos do poder punitivo estatal, tendo sido estabelecidos justamente para limitá-lo. E limitá-lo não em prol apenas de delinquentes, mas sim de todos os cidadãos, que, um dia, podem se ver injustamente no banco dos réus, quando só então entenderão a importância do respeito ao devido processo legal constitucional e às regras que edificam o Estado Democrático de Direito.

Nesse ponto, salutar rememorar as palavras proferidas pelo Ministro Nefi Cordeiro por ocasião do julgamento do Habeas Corpus nº 509.030-RJ: "Juiz não enfrenta crimes, juiz não é agente de segurança pública, não é controlador da moralidade social ou dos destinos políticos da nação.... O juiz criminal deve conduzir o processo pela lei e Constituição, com imparcialidade e, somente ao final do processo, sopesando adequadamente as provas, reconhecer a culpa ou declarar a absolvição. Juiz não é símbolo de combate à criminalidade, é definidor da culpa provada, sem receios de criminosos, sem admitir pressões por punições imediatas".

II.B – DOS ENTORPECENTES LOCALIZADOS FORA DA RESIDÊNCIA, NO GINÁSIO EM CONSTRUÇÃO ABANDONADO

Com em relação às 07 pedras de "crack" encontradas em lugar de onde o acusado teria saído, entendo que não foram produzidas pela Acusação provas suficientes para vincular a substância ao acusado.

As porções foram encontradas em local próximo de onde o réu estava, mas não com o réu, sem nenhum elemento que vinculasse o acusado a essa situação.

Ressalte-se que, conforme se extrai dos depoimentos colhidos em sede policial e em juízo, a localização de tais drogas se deram em momento posterior à invasão domiciliar. O indiciado e os policiais militares se dirigiram à residência do acusado e, somente após, retornando ao local de onde Abraão teria fugido, é que localizaram as substâncias. Assim, não há como imputar a autoria a Abraão, primeiramente porque os entorpecentes não foram localizados com ele e não há relatos de testemunhas que tenham presenciado o seu descarte por ele. Em segundo lugar e como consequência, os entorpecentes poderiam pertencer a terceiros que ali abandonaram a droga, especialmente por se tratar de ginásio em construção, com acesso aberto ao público.

Ora, havia a possibilidade da produção de outras provas. O ônus probatório no

processo, ainda que penal, deve ser tão intenso quando a capacidade da parte de dele se desincumbir. Por conclusão, exige-se um ônus probatório menor naqueles crimes ocultos, cometidos na clandestinidade; exige-se um rigor probatório maior naqueles crimes cometidos à vista de testemunhas. Não sem razão, dispõe o art. 6º, inciso III do Código de Processo Penal determina: "Logo que tiver conhecimento da prática da infração penal, a autoridade policial deverá: (...) colher todas as provas que servirem para o esclarecimento do fato e suas circunstâncias".

No caso em apreço, chama a atenção o fato de que, tendo sido encontradas drogas próximo do local onde estava o réu, nenhuma medida de investigação foi adotada para determinar a vinculação entre a droga e o acusado.

Se isso não ocorreu, não se pode relativizar e reduzir o ônus probatório da Acusação em prejuízo do acusado. Tais circunstâncias conduzem à conclusão que o acusado não tem responsabilidade por referidas porções de drogas.

Por outro lado, a prova produzida na fase de inquérito não tem aptidão para sustentar uma condenação. Uma vez iniciada a ação penal, as provas ontologicamente repetíveis coletadas na fase inquisitorial não servem para fundamentar a condenação, pois são uma prova precária produzida em sede policial sem o contraditório.

A prova produzida na fase inquisitorial serve tão somente para subsidiar o convencimento do órgão acusador e permitir o oferecimento da denúncia, salvo se irrepetível. O Poder Judiciário existe e justifica-se em função da garantia à Jurisdição: como seu consectário lógico, exsurge a garantia de ser julgado com base na prova produzida dentro do processo, com todas as garantias do devido processo penal.

São atos de prova os atos dirigidos a convencer o juiz de uma afirmação para o julgamento final, no processo e a serviço do processo e da sentença, exigindo a estrita observância à publicidade, contraditório e imediação, praticados sob a visão e a supervisão do Juiz de Direito. Por outro lado, são atos de investigação aqueles dirigidos não a uma afirmação, mas a uma hipótese; estão a serviço da investigação preliminar e servem para formar um juízo de probabilidade – não a convicção do juiz; não exigem observância da publicidade, contraditório e imediação, princípios que podem ser restringidos; servem à formação da opinião delicti do acusador, demonstrando o *fumus commissi delicti* para justificar o processo (recebimento da ação penal) ou o não processo (arquivamento) e são praticados pelo Ministério Público ou polícia judiciária. São os atos de prova que podem fundamentar uma condenação, mas não os atos de investigação.

Em que pese a gravidade dos fatos imputados, isso não é razão suficiente para assumir o risco do erro judiciário em que consistiria a condenação no presente caso, pois o conjunto probatório é demasiadamente frágil. Nisso consiste o mandamento de otimização contido no princípio do *in dubio pro reo*.

Em um modelo garantista, em que devem ser respeitados os princípios e garantias da pessoa submetida ao processo penal a fim de evitar abusos estatais que interfiram em sua liberdade, dúvidas consideráveis devem ser resolvidas favoravelmente ao réu. Assim ensina LUGI FERRAJOLI ao concluir que "A certeza perseguida pelo direito penal mínimo está, ao contrário, em que nenhum inocente seja punido à custa da incerteza de que também algum culpado possa ficar impune" (Direito e Razão. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2002, p. 85).

Ademais, não há qualquer prova de mercancia da droga.

Com essas observações, é mesmo caso de ABSOLVER o réu da imputação do artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06 com relação às 07 porções de "crack" encontradas em

lugar de onde ele teria saído.

III - DISPOSITIVO.

Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão punitiva estatal para ABSOLVER o réu ABRAÃO TEODORO MARCOS, qualificados nos autos, das imputações previstas no Art. 33, caput, e §1º, inciso II, ambos da Lei n. 11.343/06, com fundamento no artigo 386, II, Código de Processo Penal (CPP).

Ante a improcedência, REVOGO a prisão preventiva e/ou quaisquer medidas cautelares fixadas em desfavor do réu.

Se o caso, expeça-se alvarás de soltura clausulado com urgência.

Se for o caso, EXPEÇA-SE certidão para remuneração do Defensor dativo, conforme tabela do convênio DPE/OAB.

Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe.

Sentença prolatada em audiência, saem intimadas as partes.

Publique-se. Cumpra-se.

Dispensado o registro (Provimento CG nº 27/2016).

Agudos, 09 de fevereiro de 2022.

ORLANDO GONÇALVES DE CASTRO NETO
JUIZ DE DIREITO TITULAR

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA